# PODER CONSTITUYENTE



CONCEPTO:

El poder constituyente es la competencia, capacidad o energía para constituír o dar constitución al Estado, es decir para organizarlo (conf. Bidart Campos).

# CLASES DE PODER CONSTITUYENTE

- ORIGINARIO
- DERIVADO

## PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO

Es aquel poder que ejerce el pueblo en la etapa fundacional del Estado para darle nacimiento y establecer su estructura. En otras palabras, es la capacidad para dictar la Constitución de un Estado.

## TITULARIDAD

El Poder constituyente originario es ejercido por el pueblo. En nuestro país tuvo lugar en el año 1853 cuando los representantes de las provincias, reunidos en el Congreso de Santa Fe dieron nacimiento al Estado y a nuestra constitución.

## LIMITES

Límites: En principio es ilimitado, ya que no existen normas superiores que lo condicionen. Pero deben tenerse en cuenta algunos elementos importantes: Por ejemplo en 1853 se tuvo en cuenta: a) el valor justicia, b) pactos preexistentes entre las provincias, c) la realidad social del país.

## PODER CONSTITUYENTE DERIVADO

Es aquel poder que se ejerce para reformar la Constitución de un Estado. En nuestro país, fue ejercido sucesivamente en las reformas de 1860, 1866, 1898,1949,1957, 1972, y 1994.

## TITULARIDAD

De acuerdo al artículo 30, el deber de reformar nuestra Constitución Nacional está a cargo de la Convención Reformadora.
Dicha convención tiene a su cargo reformar la constitución de acuerdo a los puntos señalados por el mismo Congreso.

## LIMITES

Límite formal: Se refiere a la necesidad de convocar un órgano especial para reformar la Constitución. Se observa en las constituciones rígidas, y no en las flexibles.
Límite sustancial: se refiere a la prohibición de modificar los contenidos pétreos.

## Discusión sobre la reforma de 1860:

En el año 1853 se dictó nuestra Constitución Nacional.
Esta establecía la prohibición de reforma por el plazo de 10 años.
Sin embargo en el año 1860, la Constitución se reformó para que la Provincia de Buenos Aires ingrese a la Confederación.
De allí surge que algunos autores (entre ellos Bidart Campos) habla de la Constitución de 1853/1860. Ellos entienden que el Poder Constituyente Originario de 1853 quedó abierto, y terminó de ejercerse en 1860. La opinión contraria sostiene que en 1860 se ejerció indebidamente el Poder Constituyente Derivado para reformar la Constitución Nacional.

# REFORMA DE NUESTRA CONSTITUCION NACIONAL

ARTÍCULO 30 CN

**ART. 30 CN:**

La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.

De la lectura del artículo surgen aspectos fundamentales de nuestra Constitución:

RIGIDEZ: Nuestra CN es rígida atento que su procedimiento se realiza mediante un procedimiento especial diferente al procedimiento que se utiliza para reformar las leyes comunes.

Este procedimiento especial se ve reflejado en el artículo 30 CN cuando establece que la reforma debe ser efectuada por una Convención, convocada específicamente para reformarla (rigidez orgánica).-

CONTENIDOS PETREOS:

Son aquellos contenidos de la Constitución que no pueden reformarse.

Sin embargo al leer la primera parte del art. 30 se podría llegar a negar la existencia de estos contenidos pétreos.

Con respecto al tema, la mayor parte de la doctrina entiende que pueden reformarse en tanto no altere su esencia.

Bidart Campos sostiene que lo prohibido sería por ejemplo

Reemplazar la democracia por el totalitarismo

Reemplazar el federalismo por el unitarismo

Sustituír la República por la Monarquía.

## ETAPAS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

a) la etapa de iniciativa o de declaración, en la que se establece que es necesario proceder a la reforma y se la impulsa.

b) la etapa de revisión propiamente dicha (o constitutiva) , en la que la reforma se lleva a cabo.

**ETAPA DE INICIATIVA** es el momento en que el Congreso declara la necesidad de reformar la Constitución.
El artículo 30 exige el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

La mayor parte de la doctrina sostiene que debe computarse sobre el total de miembros del Congreso, ya que la cuando la Constitución pretende que el quórum se calcule sobre los miembros presentes, incluye la palabra presentes.
Se computa por cada cámara por separado.

El Congreso debe puntualizar los contenidos o artículos que deben ser reformados.

La Convención no se encuentra obligada a introducir cambios en los puntos señalados , pero no puede excederse de esos puntos.

**ETAPA DE REVISION**: es el período en que se produce la reforma , llevado a cabo por la Convención Reformadora. El artículo 30 CN no especifica como se integra la Convención.

La Convención al momento de reformar tiene ciertos límites:

1. Los contenidos pétreos.
2. No puede extenderse más allá de los puntos señalados por el Congreso.
3. El plazo para reformar. Este plazo es establecido por el Congreso y su vencimiento provocaría automáticamente la disolución de la Convención.

# EL GOBIERNO REPRESENTATIVO, REPUBLICANO Y FEDERAL

"La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana federal, según lo establece la presente constitución."

**FORMA REPRESENTATIVA**, implica que el pueblo se gobierna a su mismo, pero a través de sus representantes. Es decir que el gobierno actúa representando al pueblo que lo eligió-

DEMOCRACIA DIRECTA: o Pura. En este tipo de gobierno, el pueblo sin representantes dicta sus propias leyes y ejerce por sí mismo las funciones del Estado. No tiene vigencia en la actualidad, ya que fue pensado para civilizaciones pequeñas y con pocos habitantes.

DEMOCRACIA INDIRECTA: O también llamada representativa. El pueblo no se gobierna por si mismo directamente, sino que elige a ciertas personas para que lo represente.

**LA FORMA REPUBLICANA**:

Deriva del latín "res publica", esto significa cosa pública, la cosa del pueblo, etc.

Según el constitucionalista argentino Aristóbulo del Valle: una República es "una sociedad organizada en base a la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el pueblo por su administración"

## CARACTERISTICAS DE LA REPUBLICA

1) Soberanía del Pueblo: La soberanía es ejercida por el pueblo a través del sufragio. El pueblo expresa su voluntad y constituye su gobierno.-

2) Igualdad ante la ley: Las leyes son aplicables de igual forma para todos los habitantes, cualquiera sea su raza, color, sexo, religión…

3) Elección popular de los gobernantes: Los integrantes del gobierno son elegidos por el pueblo a través del voto popular.

4) Periodicidad en el ejercicio del poder: No existe ningún cargo perpetuo en el gobierno. Todos los cargos son desempeñados durante un lapso determinado.

5) Responsabilidad de los gobernantes: Los gobernantes son responsables ante los ciudadanos por los actos de gobierno que realicen. Deben ajustar sus conductas a las leyes, y de no hacerlo pueden ser sancionados.

6) Publicidad de los actos de gobierno: Los gobernantes deben informar al pueblo sobre los actos que realicen desempeñando las funciones de gobierno.

7) División de poderes: Consiste en distribuir el poder del estado en diferentes órganos. (Ejecutivo, legislativo y Judicial). De esta forma se evita la concentración de poder en un solo órgano.

## FORMA FEDERAL

Concepto: Decimos que un país adopta la forma federal, cuando está compuesto por entidades autónomas, denominadas provincias. Las provincias son unidades autónomas e independientes unas de las otras, pero no son soberanas, ya que la soberanía la delegan en el gobierno central.

# SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

Es definida como la "doctrina según la cual, las normas de la constitución Nacional prevalecen sobre todas las demás normas." Ossorio

La Constitución Nacional es la norma fundamental hacemos referencia a que todo el ordenamiento jurídico de un estado deberá basarse en la misma, y ser compatible.

Surge claramente de la Constitución Nacional que establece:

Artículo 31 primera parte: "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley Suprema de la Nación..."

El artículo 27 CN, expresa: "EL gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución".

Claramente podemos observar que de este articulo surge que los Tratados en general se encuentran en un rango inferior que la Constitución Nacional.

El artículo 75 inc 22 establece en el primer párrafo "… Los Tratados y Concordatos tienen jerarquía superior a las Leyes…"

Sin embargo, el artículo 75 inc 22 en el segundo párrafo, modificado por la reforma de 1994, menciona a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos, y dispone respecto de ellos, que "en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta constitución, y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos…"

Esos once instrumentos son:
- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Asamblea ONU, 16- 12-1948); - La Declaración Universal de Derechos Humanos (IX Conferencia Internacional Americana Bogotá, 1948. Decreto Ley 9983/57) - La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969. Ley 23054) - El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Asamblea general de la UN del 16-12-1966. Ley 23.313); - El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo (Asamblea general de la UN del 16-12-1966. Ley 23.313); - La Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Asamblea general de la UN del 9-12-1948. Ley 6286/56); - La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Asamblea general de la UN del 21-12-1965. Ley 17.722); - La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Asamblea general de la UN del 18-12-1970. Ley 23.179); - La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Asamblea general de la UN del 10-12-1984. Ley 23.338); - La Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea general de la UN del 20-12-1989. Ley 23.849).

El artículo 75 inc 22 en el último párrafo agrega también que los demás tratados sobre derechos humanos podrán adquirir jerarquía constitucional con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso.

Así ocurrió con:

- La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en 1997.-
- La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, en 2003

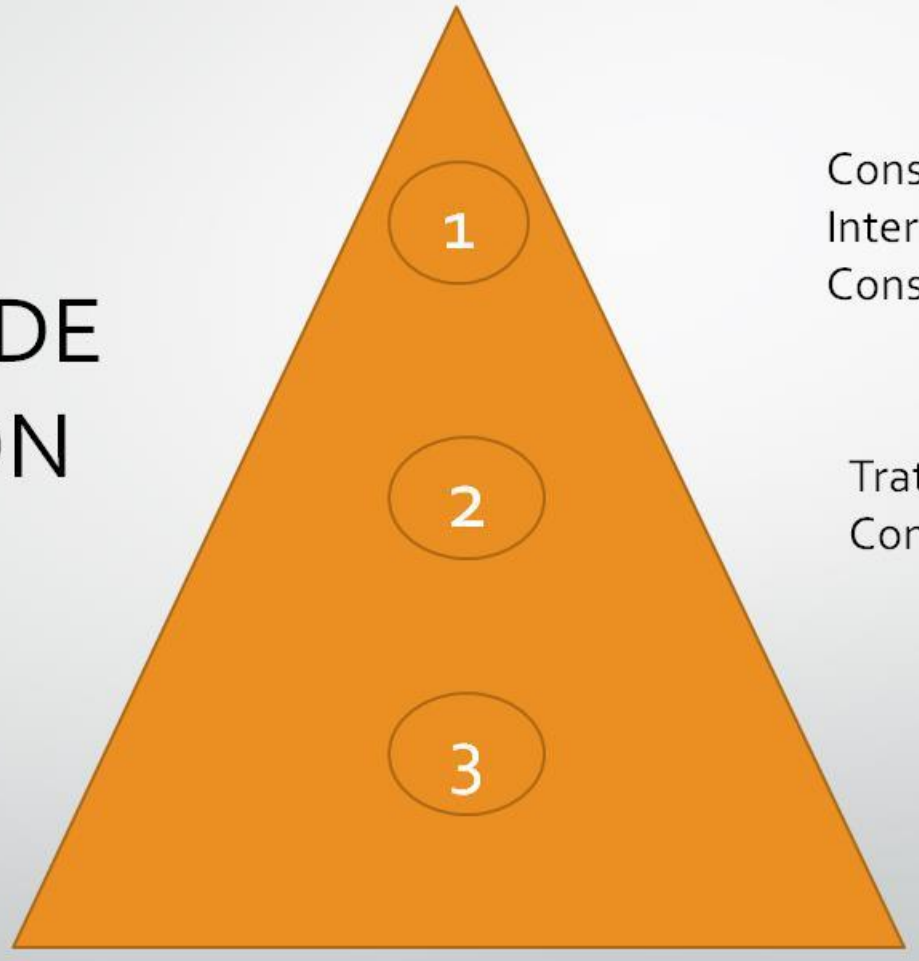
El orden jerárquico conforme a lo opinado por la mayoría de los autores, quedaría conformado de la siguiente manera:

En el primer nivel Jerárquico: La totalidad de la Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales con Jerarquía constitucional (recordar que antes de la reforma de 1994, únicamente ocupaba este nivel la Constitución Nacional)

En el segundo nivel Jerárquico: Tratados Internacionales y concordatos sin jerarquía constitucional (según el artículo 27 CN se encuentran por debajo de la Constitución, y de acuerdo al artículo 75 inciso 22, primer párrafo, se encuentran por encima de las Leyes de la Nación.

En el tercer nivel jerárquico: Leyes Nacionales (que se encuentran por debajo de cualquier Tratado)

# PIRAMIDE DE PRELACION




Constitución Nacional e Instrumentos Internacionales con Jerarquía Constitucional

Tratados sin Jerarqía Constitucional

Leyes Nacionales

Artículo 31, segunda parte: “… y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales,….”

La segunda parte del artículo se refiere a la superioridad del derecho federal sobre el derecho local o provincial.